



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/175/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

הללי שייקה, ת"ז 072411465
באמצעות ב"כ: עו"ד מנחם גרון
ההסתדרות 2, פתח תקווה
טל': 9130600 פקס': 9130609

התובע:

נגד

שמש הדר חברה קבלנית לבניין בע"מ, ח.פ. 510375231
באמצעות ב"כ: עו"ד צביקה ציפוק
גולדנהירש 24, פתח תקווה
טל': 9313990 פקס': 9346110

הנתבעת:

פסק דין

1. תביעה למתן צווי עשה שהגיש הבעלים של נכסים בבית משותף המשמש בנין משרדים ומסחר, נגד בעלים של נכסים אחרים בבית, בקשר עם שימוש ברכוש המשותף בבית המשותף. נותר לדיון ולהכרעה אך סעד למתן צו עשה המורה לנתבעת לפתוח שלושה חלונות שנאטמו ברכוש המשותף בבית המשותף.

העובדות וההליכים

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב חובבי ציון 40 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 288 בגוש 6380 (להלן - "הבית המשותף"). הבית מורכב ממבנה אחד בן 6 קומות (קומת קרקע תחתונה, קומת קרקע ו-4 קומות מעל הקרקע) הכולל 45 דירות המשמשות למסחר, שעיקרן חנויות, משרדים ומחסנים. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר נרשם ביום 17.6.2008 עם מתן צו לרישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/175/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התביעה דנן היא תביעה שכנגד, אשר נותרה לדיון ולהכרעה לאחר שביום 22.10.2018 ניתן במעמד הדיון פסק דין בתביעה העיקרית (תיק תביעה מספר 6/101/2017).

4. התובע, הללי שייקה (להלן - "התובע"), הוא הבעלים או הזכאי להירשם בעלים מכוח הסכמי מכר של מרבית הדירות בבית המשותף המצויות בקומות הראשונה עד הרביעית והמשמשות משרדים (רשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 22, 23, 25, 27-45). הנתבעת, שמש הדר חברה קבלנית לבניין בע"מ (להלן - "הנתבעת"), היא הבעלים של דירות אחרות בבית המשותף המצויות בקומת הקרקע התחתונה, בקומת הקרקע ובקומה הראשונה בבית, והמשמשות אולמות מסחר, חנויות ומחסנים (רשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 1, 2, 4, 20 ו-21).

5. בכתב התביעה עתר התובע למתן צווי עשה בקשר עם שימוש ברכוש המשותף בבית המשותף, המורים לנתבעת, כך כלשון כתב התביעה, כדלקמן: לפתוח שלושה חלונות שסגרה בחדר המדרגות ומול משרד התובע בבית המשותף; לפתוח דלת חירום ולאשר שימוש במפתח של דלת זו שניתן בידי התובע; לנקות ולפנות ציוד משטח מעבר בבית המשותף מנקודת הירידה למקלט ועד לדלת החירום; להפסיק להפריע לתובע בשטח גג הבית המשותף הצמוד לו, לרבות הסרת הפגיעה בזכויות הבניה; להרוס מבנים שנבנו ללא היתר על גג הבית המשותף; להיכנס לכניסה הראשית לבנין רק לפי הצורך, לא להפריע השימוש לתובע ולדייריו ולא למסור מפתח דלת הכניסה לאחרים. עוד עתר התובע למתן צו הצהרתי, לפיו הבנין נבנה כיחידה נפרדת טרם בניית הבית המשותף, לרבות המקלט המיועד רק לדיירי הבנין, ולכן חל איסור לשימוש הנתבעת במקלט אלא במקרה חירום.

כנטען, הנתבעת עושה ברכוש המשותף בבית כאוות נפשה ומשתלטת על רכוש זה. בכלל זאת, השתלטה הנתבעת על אזור יציאת החירום, סגרה דלת יציאת החירום והשליכה ציוד רב במעבר מנקודת הירידה למקלט ועד לדלת יציאת החירום. עוד כנטען, הבית המשותף הוא גדול מימדים, משתרע כמעט עד קצה רחוב קציר, ולכן לא ייתכן כי אין בבית המשותף מקלט נוסף. על הנתבעת לגלותו, כך לשון כתב התביעה, ולחלופין לבנות מקלט כאמור או כל מרחב מוגן אחר (ממ"ד). עוד כנטען,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/175/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנתבעת אין צורך להיכנס לבנין, וככל שכן עליה לעשות כן דרך דלת כניסה שפערה
שלא כדין עבור גן ילדים בנכס שבבעלותה בבית המשותף. התובעת הוסיפה וטענה
כי הנתבעת סגרה חלונות בחדר מדרגות ומול משרד התובע.

6. בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת הנטען בכתב התביעה. הנתבעת לא השתלטה על
חלקים ברכוש המשותף, לרבות יציאת החירום והמעבר המוביל אליה. הנתבעת
עושה שימוש ברכוש המשותף בבית, לרבות במדרגות הבנין ובכניסה לו, כדין
מכוח זכויותיה הקנייניות בהם. עוד כנטען, מעולם לא היתה דלת יציאת חירום בבית
המשותף. הנתבעת היא שדואגת לניקיון הבית המשותף, על חשבונה ולטובת כלל
בעלי הנכסים בבית המשותף. טענות התובע לעניין חיוב הנתבעת בבניית מרחב
מוגן (קומתי או דירתי) מקומן אל מול רשויות התכנון הרלוונטיות, ובהתאם
להוראות הדין בעניין. הנתבעת הכחישה כי אטמה חלונות ברכוש המשותף בבית
המשותף, בציינה כי החלונות נסגרו על ידי הבנק הבינלאומי לפני 26 שנה (בשנת
1994).

7. ביום 22.10.2018 התקיימה ישיבת קדם משפט בתביעה לפני כבוד המפקחת על
רישום מקרקעין, טלי להב. בהחלטה ממועד זה הורתה בירור התביעה על דרך של
שמיעת ראיות. בתוך כך, הורתה מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד
לישיבת הוכחות.

8. הצדדים הגישו תצהירי עדותם הראשית.

9. ביום 25.9.2019 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות, לאחר שהתביעה עברה
לטיפול. בפתח הדיון ולאחר בירור הפלוגתאות, הורתי בהסכמת הצדדים, כי
הסעד שנותר לבירור ולהכרעה הוא אך הסעד למתן צו עשה המורה לנתבעת לפתוח
שלושה חלונות שנאטמו ברכוש המשותף. בהתאם, נחקרו הצדדים על תצהיריהם
בסוגיה זו.

10. לבקשת הצדדים, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

עיקרי טענות הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/175/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. בטענת התובע, דין התביעה להתקבל. הוכח כי הנתבעת היא שאטמה החלונות בחדר המדרגות ומול משרדו של התובע, מבלי שיש בידה היתר כדין לעשות כן ואישור נציגות הבית המשותף. מכל מקום, עדותו של מנהל הנתבעת היתה רצופת שקרים וסתירות, ובגדרה הודאתו כי הנתבעת היא שאטמה החלונות. מנהל הנתבעת כלל לא התייחס בתצהירו לנושא פירוק הנתבעת (חברה) ולכך שהנתבעת, לרבות באמצעות כונס הנכסים כפי טענת מנהל הנתבעת, אטמה חלונות אלה.

12. בטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות. מנהל הנתבעת אישר בעדותו כי בניה שבוצעה בבית המשותף בשנת 1994 נעשתה בהתאם להיתר בניה כדין, וכי מאז לא השתנה דבר בבית המשותף. התובע לא הוכיח כי המצב הקיים לעניין חלונות הבית המשותף אינו תואם היתר הבניה של הבית המשותף, וכן ככל שנאטמו חלונות בניגוד להיתר הבניה, נעשה הדבר על ידי הנתבעת. זאת, הגם שנטל ההוכחה רובץ לפתחו של התובע. מכל מקום, התובע לא הלין על בניה שאינה כדין, לרבות איטום חלונות ברכוש המשותף בבית, במשך 25 שנה, וככל שהיה בסיס לטענת התובע בעניין זה, מקומה לפני רשויות התכנון המוסמכות.

דיון והכרעה

13. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובחנתי התשתית הראייתית שהונחה לפניי, הנני להורות על דחיית התביעה. אביא טעמי למסקנה זו.

14. מושכלות יסוד הן בשיטת משפטנו, כי נטל השכנוע במשפט האזרחי מוטל על התובע, שכן "המוציא מחברו עליו הראיה". נטל השכנוע הוא בבחינת "החובה העיקרית במשפט", ומשמעו החובה המוטלת על בעל דין להוכיח טענותיו במידת ההוכחה הנדרשת במשפט, אשר נקבעה במשפט האזרחי על פי מאזן ההסתברויות. אי עמידה בנטל השכנוע משמעה דחיית טענותיו של מי שנטל זה רובץ לפתחו. בתוך כך, מוטל על התובע נטל הבאת הראיות, המתאר "החובה המשנית הנלווית לנטל השכנוע". בבחינת נטל דיוני, המוטל על בעל הדין להביא ראיותיו כדי לעמוד בנטל השכנוע. כלשון כבוד השופט צ' זילברטל בהחלטה ברע"א 1530/13 גדלוב נ' הארגז מפעל תחבורה בע"מ, פורסם ב"נבו" (5.5.2013): "כאשר הצד שנשא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/175/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בנטל הבאת הראיות הביא די ראיות כדי להוכיח את טענתו, עובר נטל זה, הנטל להביא ראיות, אל בעל הדין השני, כדי שזה יביא ראיותיו מצדו במטרה להוכיח את טענתו ולהפריך את טענתו של הראשון. "עוד הוטעם בהחלטה, לאמור: "השאלה על מי מוטל נטל השכנוע רלוונטית ככלל רק מקום בו בעלי הדין לא הציגו ראיות, או מקום בו לאחר הערכת מכלול הראיות שהונחו בפני בית המשפט, נקבע כי כפות המאזניים מעויינות, דהיינו שקיים 'ספק שקול'. ... כלומר, מקום בו ניתן להגיע להכרעה על פי התשתית הראייתית שפרשו הצדדים בפני בית המשפט, ולקבוע כי לאחד מבעלי הדין עדיפות ראייתית על משנהו - וכך ראוי שייעשה במרבית המקרים, אלא אם כן, מטעמים טובים שיפורטו, לא ניתן לעשות כן - השאלה על מי מוטל נטל השכנוע היא ככלל חסרת נפקות." (ראו גם: ע"א 641/66 אריה נ' קליבנסקי, פ"ד כא(2) 358 (1967); ע"א 6205/98 אונגר נ' עופר, פ"ד נה(5) 71 (2001); ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ, פ"ד סא(3) 18 (2006); י' קדמי על הראיות חלק רביעי - הדין בראי הפסיקה, תש"ע-2009, 1719-1761).

ומן הכלל אל הפרט.

15. בכתב התביעה כל שטען התובע בעניין אטימת החלונות הוא כי "הנתבעת סגרה 2 חלונות בחדר המדרגות ואחד מול משרד התובע." (סעיף 12 לכתב התביעה המתוקן). התובע לא הביא בכתב התביעה כל פירוט עובדתי כנדרש לעניין תיאור הבית המשותף על מתקניו וחלונותיו לרבות מיקומם, כנתמך בהיתר בניה או בתשריט הבית המשותף, עובר לסגירת החלונות כנטען ולאחריה.

16. בתצהיר עדותו הראשית, שב התובע על טענתו בכתב התביעה, לפיה "הנתבעת סגרה 2 חלונות בחדר המדרגות ואחד מול משרד שלי" (סעיף 14 לתצהיר עדותו הראשית). אין בתצהיר עדותו הראשית של התובע כל אסמכתה להוכיח כי בבית המשותף נאטמו חלונות, אשר היו בבית לכתחילה, ומיקומן. בתוך כך, אין בתצהיר עדותו הראשית של התובע כל אסמכתה לתמוך טענתו כי הנתבעת היא שאטמה חלונות בבית המשותף. בעניין זה, העיד התובע בחקירתו הנגדית לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/175/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"ש: תאשר לי שאתה לא ראית את שמש [מנהל
הנתבעת] סוגר את החלונות.

ת: ברור שלא ראיתי, אני שומר את הבניין? אז מי סגר
אם לא הוא? בא עשה גן ילדים, זה הפריע לו אז הוא
סגר. ... מה אני עוקב אחריו? מה הוא פוטוגני?"

(שורות 6-9 בעמוד 8 לפרוטוקול הדיון מיום
25.9.2019).

17. כאמור, הנתבעת הכחישה כי אטמה החלונות בבית המשותף. לטענתה בכתב ההגנה
ובתצהיר עדותה הראשית, החלונות נבנו כפי מצבם היום כבר בשנת 1994, קודם
לרכישת הדירות בבית המשותף על ידי הנתבעת (סעיף 14 לתצהיר עדותו הראשית
של מנהל הנתבעת). כלשון מנהל הנתבעת בעדותו לפני:

"ש: תראה לי בתצהיר שלך איפה כתבת שיש לך תצהיר
[צ"ל: היתר/הסכמה] לסגור את החלונות?

ת: על מה אני אראה לך בתצהיר דבר שקיים 30 שנה?

...

ש: אני לא רואה בתצהיר שלך, ושוב אני אומר, מילה
וחצי מילה לגבי הטענה שלנו שאתה סגרת את החלונות.

ת: אם הייתי סוגר הייתי כותב, אני לא סגרת.

(שורות 15-22 בעמוד 9 לפרוטוקול הדיון מיום
25.9.2019).

18. בחקירתו הנגדית עמד מנהל הנתבעת על כך שככל שנאטמו החלונות, הדבר נעשה
בשנת 1994 ושלא על ידי הנתבעת (שורות 8-27 בעמוד 10, שורה 10 בעמוד 11
ושורות 1-8 בעמוד 12, לפרוטוקול הדיון מיום 25.9.2019).

19. בנסיבות אלה, באתי לכלל מסקנה כי לא עלה בידי התובע לעמוד בנטל ההוכחה
הרובץ לפתחו. התובע לא הניח כל תשתית ראיינית להוכיח כי חלונות ברכוש
המשותף, מושא כתב התביעה, אכן היו קיימים בבית המשותף בהתאם להיתר בניה
מכוחו נבנה הבית. בתוך כך, לא הניח התובע תשתית ראיינית להוכיח, על פי מאזן
ההסתברויות, כי הנתבעת היא שאטמה החלונות ברכוש המשותף בבית, כנטען.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/175/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משלא עלה בידי התובע להניח תשתית ראייתית לבסס תביעתו, ממילא לא עלה בידו להרים נטל השכנוע המוטל עליו להוכיח טענתו מכוחה עתר לסעד המבוקש.

20. לפיכך, הנני להורות על דחיית התביעה.

21. אשר לפסיקת הוצאות המשפט, לאחר שנתתי דעתי לאמות המידה שהותוו בפסיקה בעניין זה ולמכלול נסיבות העניין, לרבות מחיקת מרבית הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה בפתח הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, הנני לחייב התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 3,000 ש"ח, הכוללות שכר טרחת עורך דין.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ו' ניסן תש"פ, 31 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה